

0001068-09.2017.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Nicole de Almeida Campos Leite Colombini

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/01/2022

... foi preso anteriormente sob acusação de tráfico de drogas (fls. 15).

Ou seja, o acusado admitiu o porte de droga para uso próprio, bem como a posse do aparelho celular.

Acerca do assunto, aliás, já se decidiu que: "A confissão extrajudicial não deve ser desprezada quando se harmoniza e se ajusta à prova colhida na instrução, sob o crivo do contraditório, sendo irrelevante se foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

1ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista - SP - cep 12902-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0001068-09.2017.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001068-09.2017.8.26.0545

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ISAIAS GABRIEL DE ANDRADE

120.748.716-35

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nicole de Almeida Campos Leite Colombini

Vistos.

ISAIAS GABRIEL DE ANDRADE, vulgo Mineiro, foi denunciado como incurso no artigo 180, §6º, do Código Penal, em concurso material com o artigo 28, caput da Lei nº 11.343/06, porque, entre 21 de julho de 2017 e 17 de outubro de 2017, em local também incerto, mas nesta cidade e comarca de Bragança Paulista/SP, adquiriu, em proveito próprio, um telefone celular, da marca "Alcatel", IMEI 356.870.067.562.476, apreendido nos autos e avaliado no montante de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), pertencente à Secretaria Municipal da Saúde de Bragança Paulista, que sabia ser produto de crime.

Consta ainda que, no dia 17 de outubro de 2017, por volta das 10h58min., na quadra de bocha da Secretaria Municipal de Esportes, Juventude e Lazer, sito à Avenida dos Imigrantes, 3237, nesta cidade e comarca de Bragança Paulista/SP, o acusado

trazia consigo, para consumo pessoal, um cigarro de maconha, pesando cerca de 0,6 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão e laudo de constatação preliminar constantes nos autos.

A denúncia foi recebida em 17.11.2017 (fls. 103/104). Em 25.11.2020 os autos foram suspensos nos termos do artigo 366 do CPP (fls. 312/313). O réu foi citado em 07.09.2021 (fls. 347) e apresentou defesa preliminar (fls. 352/353). Revogada a suspensão processual, foi retomada a tramitação do feito (fls. 354/355).

Durante a instrução foi produzida a prova oral, com a oitiva da representante legal da vítima e testemunha comum, através do sistema audiovisual. Foi decretada a revelia do acusado (fls. 399/400).

Encerrada a instrução, as partes se manifestaram em alegações orais.

O Representante Ministerial, após analisar as provas dos autos, opinou pela parcial procedência da ação, com a condenação do acusado pelos crimes de receptação simples e porte de drogas para consumo. Requereu o afastamento da qualificadora prevista no §6º do artigo 180 do Código Penal. Também postulou pela decretação da extinção da punibilidade do acusado para o delito previsto no artigo 28 da lei de tóxicos, mediante a compensação do período de prisão cautelar efetiva nos autos. A Defesa, em suma, diante da confissão extrajudicial do acusado, teceu comentários acerca da dosimetria da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação procede em parte.

Inicialmente, observo que a materialidade delitiva do delito de receptação depende da comprovação do crime anterior, no caso, o furto do aparelho celular. Neste sentido, há nos autos o boletim de ocorrência de fls. 24/25, que evidencia sua ocorrência. No mais, para ambos os tipos penais, há nos autos o auto de prisão em flagrante (fls. 06), o boletim de ocorrência (fls. 17/19), o auto de exibição e apreensão (fls. 20/21), o auto de constatação preliminar (fls. 28), o auto de avaliação (fls. 40), o laudo químico-toxicológico (fls. 108/109) e a prova oral colhida nos autos.

A autoria também restou comprovada.

O acusado apenas foi ouvido na fase extrajudicial. Informou que comprou o telefone celular de um usuário de drogas, pelo valor de cinquenta reais. Não tinha conhecimento de que o produto era objeto de furto. Acrescentou que estava dentro da área da Secretaria de Esportes, junto de outras duas pessoas, fumando um baseado. Na ocasião foi abordado por guardas municipais. Na revista, eles encontraram em seu poder o telefone celular e uma ponta de cigarro de maconha. Por fim mencionou que já foi preso anteriormente sob acusação de tráfico de drogas (fls. 15).

Ou seja, o acusado admitiu o porte de droga para uso próprio, bem como a posse do aparelho celular.

Acerca do assunto, aliás, já se decidiu que: “A confissão extrajudicial não deve ser desprezada quando se harmoniza e se ajusta à prova colhida na instrução, sob o crivo do contraditório, sendo irrelevante se foi obtida na fase do inquérito policial” (RT 742/605 – TJSP – Ap. 201.834-3/2 – Rel. Des. Jarbas Mazzoni)

Ademais, a prova oral apenas confirmou a confissão extrajudicial do acusado.

A representante legal da vítima Giuliana Venturi Falabella Pereira Leme informou que, na época do furto do aparelho celular, trabalhava como enfermeira responsável da unidade de saúde. Conforme orientação da Secretaria Municipal da Saúde, ela lavrou boletim de ocorrência a respeito do fato, pois foram subtraídos diversos bens pertencentes ao patrimônio público, dentre eles o aparelho celular em questão. Posteriormente, a polícia conseguiu recuperar um aparelho celular pertencente à unidade, porém a depoente não soube especificar se era o bem subtraído naquela data, pois vários foram os furtos no local. Por fim, mencionou que o aparelho celular subtraído não tinha qualquer identificação de patrimônio público.

O guarda municipal Adalto de Jesus Prado informou que estava em patrulhamento pelo local dos fatos e efetuou a abordagem de três indivíduos. Eles alegaram que estavam juntos e consumiam entorpecente. Com o acusado foi encontrado um cigarro de maconha e um aparelho celular. Os demais indivíduos foram liberados. Após efetuar

pesquisas, o depoente constatou que o aparelho celular era produto de furto. O acusado foi detido.

Consoante se extrai dos depoimentos acima, há prova segura acerca da responsabilidade criminal do acusado.

A prova oral revelou que o acusado foi flagrado na posse do aparelho celular, sendo que a diligência policial confirmou se tratar de produto de furto.

Cumpra ressaltar que o relato do guarda municipal Adalto, é coeso, no tocante à abordagem e apreensão do aparelho celular em poder do acusado. Posteriormente, foi identificada a origem espúria do objeto.

Da mesma forma, deve-se ressaltar que Giuliana, representante legal da Municipalidade, confirmou a incidência do furto do aparelho celular na época dos fatos, e que posteriormente foi recuperado pela polícia.

O acusado, por sua vez, ouvido na fase extrajudicial, admitiu a prática da receptação, pois confirmou que adquiriu o aparelho celular de um usuário de drogas, pelo valor ínfimo de cinquenta reais. Portanto, é evidente que estava ciente acerca da origem espúria do bem.

Ademais, o dolo do crime em questão se extrai das circunstâncias que envolveram a aquisição do bem, uma vez que, notadamente, o réu agiu com pleno conhecimento do ato ilícito que praticava.

Mas não é só. O aparelho celular foi imediatamente identificado pela polícia como produto do furto que estava sendo apurado no boletim de ocorrência nº 3846/2017, lavrado em 21 de julho de 2017.

E como é sabido, em casos de receptação, o fato de ser a pessoa detida na posse de produto de crime gera presunção de responsabilidade criminal, invertendo-se o ônus da prova. Assim, tinha o réu a obrigação de se desvencilhar da imputação do delito com uma justificativa plausível.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência: TACRSP: "Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autorizando, assim, a condenação" (RT 746/629).

No mesmo sentido: "Em se tratando de crime de receptação dolosa, a demonstração de que o agente tinha ciência sobre a origem ilícita da coisa pode ser deduzida de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento ab externo, do modus operandi do comprador, uma vez que, não se podendo penetrar no foro íntimo do agente, não há como aferir-se o dolo de maneira direta ou positiva" (RJDTACRIM 35/285)

Portanto, a confissão extrajudicial do acusado; a palavra do agente público que apreendeu o aparelho e teve contato com o acusado; o preço pago pelo bem e seu valor (cf. auto de avaliação de fls. 40), levam à conclusão de que o réu sabia da origem espúria do bem..

No entanto, é necessária a desclassificação para o crime de receptação simples, com o afastamento da qualificadora prevista no §6º do artigo 180 do Código Penal. Inicialmente, a respeito da questão, deve-se ressaltar que não há evidência de que o acusado tinha ciência de que o bem surrupiado era patrimônio público. Mesmo porque, a funcionária pública Giuliana informou que não havia qualquer sinal de identificação patrimonial no aparelho celular.

Mas ainda que fosse o contrário, não seria possível responsabilizar o acusado pela prática de receptação qualificada.

Destarte, pela análise dos autos, verifica-se que o acusado se apoderou da "res furtiva" durante o período compreendido entre 21.07.2017 (data do furto) e 17.10.2017 (data da apreensão do bem em seu poder). Porém, deve ser observado que a Lei nº 13.531/2017, que alterou o Código Penal e acrescentou a respectiva qualificadora, entrou em vigor em 07.12.2017, data de sua publicação.

Desse modo, deve-se aplicar o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, conforme preceitua o artigo 5º, XL da Constituição Federal

Nesse sentido: "1-) Apelação criminal. Receptação de bem do patrimônio público.

Parcial provimento do recurso. 2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Elemento subjetivo

do tipo (dolo) demonstrado pelas circunstâncias do caso concreto, pois evidenciaram ciência da origem espúria do colete balístico então apreendido, a impedir a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade de conduta. 3-) Necessária desclassificação para a figura do "caput", do artigo 180, do Código Penal, porque o delito foi praticado antes da vigência da Lei nº 13.531/2017, que incluiu o tipo penal do § 6º. Aplicação do princípio da irretroatividade de lei penal mais gravosa. 4-) Modificação da pena, a fim de aplicar-se a sanção cominada no "caput", mantendo-se, porém, os mesmos critérios de dosimetria previstos na r. sentença.

Primeira fase. Sanção aumentada em 1/2, porque o apelante revelou possuir personalidade voltada para a prática de delitos. Inexistência de violação ao enunciado da Súmula 444, do STJ. Utilização de condenação definitiva referente a fato anterior ao versado nestes autos, com trânsito em julgado posterior. Segunda fase. Penas reconduzidas ao piso, diante da presença das atenuantes da menoridade penal e confissão espontânea. Terceira fase. Inexistem causas de aumento ou diminuição. Reprimendas, agora, fixadas em um ano (1) de reclusão e dez (10) dias-multa. 5) Regime que não se modifica, inicial fechado, pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis. 6-) Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, as quais evidenciam que a medida não é suficiente nem adequada para prevenir a reiteração delitiva. (TJSP; Apelação Criminal 0022200-36.2015.8.26.0564; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/08/2019; Data de Registro: 16/08/2019)

Assim, de rigor a desclassificação do delito tipificado na denúncia (receptação qualificada), para condenação do acusado pelo crime de receptação simples. Apurou-se também que o acusado incorreu na conduta de mero uso ilícito de entorpecente, uma vez que o laudo químico-toxicológico comprovou que o entorpecente apreendido em seu poder era da espécie maconha (fls. 108/109).

No mais, diante da certeza da materialidade e da autoria delitivas, passo a dosar a pena a ser-lhe imposta.

No tocante ao delito de receptação, considerando-se as circunstâncias previstas no artigo 59, do Código Penal, diante de sua primariedade, não vislumbro motivos que ensejem a exasperação da pena inicial de 1 ano de reclusão e pagamento de 10 dias multa.

Na segunda fase, de rigor o reconhecimento da atenuante de confissão, ainda que na fase extrajudicial, pois relevante para a instrução criminal. Porém, não tem o condão de reduzir a pena base, conforme os termos da Súmula nº 231 do STJ. Na terceira fase de aplicação de pena não existem causas de aumento ou de diminuição da pena. Torno a pena definitiva.

Fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, em virtude da primariedade do réu e o fato de não ter incorrido em crimes com uso de violência contra pessoas.

Presentes os pressupostos, substituo a pena privativa de liberdade imposta por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, por igual período.

No tocante ao delito previsto no artigo 28 da lei de tóxicos, atenta à finalidade das medidas, mas, ainda, ao fato de ter permanecido algum tempo detido neste feito, aplico-lhe a advertência e que dou por cumprida, descontado o período de prisão. O acusado respondeu ao processo em liberdade e assim poderá permanecer, caso queira recorrer desta sentença.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para DESCLASSIFICAR o crime de receptação qualificada, previsto no artigo 180, §6º do Código Penal, para o delito na modalidade simples, nos termos do artigo 180, caput, do Código Penal, e condenar o réu ISAÍAS GABRIEL DE ANDRADE, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 01 ano de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, fixados estes no valor unitário mínimo legal, vigente à época dos fatos, em regime inicial aberto, com possibilidade de recurso em liberdade e com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade; e também como incurso no artigo 28 da Lei

11.343/06, à pena de advertência, sendo este delito já devidamente cumprido.

Após o trânsito em julgado desta, inscreva-se o nome do acusado no livro rol dos culpados e comunique-se a Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

O acusado fica isento do pagamento das custas e despesas processuais, uma vez que beneficiário da Justiça Gratuita.

P.I.C.

Bragança Paulista, 26 de janeiro de 2022.

Nicole de Almeida Campos Leite Colombini
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA